

第70問

資産家を狙った連続窃盗被疑事件で警察から追われている甲は、前科があり執行猶予中であったことから、今度は実刑判決を受けることになるかもしれないと思い、何としてもそれを避けなければならないと考えた。そこで、甲の父親である乙に対して、「万が一、俺が捕まったら次は実刑かもしれない。そこで、身代わりとして警察に出頭してくれないか。」と頼み、乙の了承を得た。

一方、乙は甲からの依頼を受ける前に、警察官から取調べを受けた際、「窃盗をしたのは、甲ではなく自分である。」との虚偽の内容を告げ、その内容どおりの警察官面前調書を作成させた。そして、乙は、甲との約束どおり、警察署へ出向き、警察官に対して、「連続窃盗事件の件だが、実は、私が真犯人である。」と述べた。警察官は、これを聞いて、乙を参考人として取り調べたが、乙の話す犯行内容が、あいまいで一貫性を欠いていたため、虚偽であると判断し、乙を逮捕せず、その後の捜査の結果、真犯人は甲であると断定し、同人を逮捕した。

甲及び乙の罪責について、論じなさい。

第1 甲の罪責

1 乙に対して身代わり犯人としての出頭を依頼した点で、犯人隠避罪の教唆犯（103、61 I）の成否が問題となる（**論点** 犯人が自らの蔵匿・隠避を他人に教唆した場合の教唆犯の成否  旧H9-2）。これを肯定的に解するのが判例である（大判昭8.10.18）。

 284 頁  149 頁

2 ただし、乙は甲の父親であって親族であるから、親族に対して犯人隠避を教唆した場合に、105条の準用があるか問題となる（**論点** 犯人が自己の親族に対して蔵匿・隠避を教唆した場合の処理  旧H9-2）。

 287 頁  151 頁

この点について、判例の立場は明確ではなく、準用肯定説と否定説が対立している。

第2 乙の罪責

1 警察に対して虚偽内容の供述をした点について、証拠偽造罪（104）の成否が問題となる（**論点** 取調べにおいて虚偽の供述をすることは「偽造」（104）に当たるか  旧H9-2）。

 286 頁  152 頁

本問では、警察官面前調書という書面が作成されているので、この点をどう捉えるかによって結論が変わる。この点については、千葉地判平7.6.2等がこれを不可罰としていたところ、近時最高裁も傍論ながら「他人の刑事事件に関し、被疑者以外の者が捜査機関から参考人として取調べ（刑訴法223条1項）を受けた際、虚偽の供述をしたとしても、刑法104条の証拠を偽造した罪に当たるものではないと解されるところ……、その虚偽の供述内容が供述調書に録取される（刑訴法223条2項、198条3項ないし5項）などして、書面を含む記録媒体上に記録された場合であっても、そのことだけをもって、同罪に当たるとすることはできない。」として同旨を述べた（最決平28.3.31【百選Ⅱ119】、ただし、当該事案では証拠偽造罪の成立を認めている。）。

この判例に従えば、上記乙の行為には証拠偽造罪は成立しない。

もっとも、犯人隠避罪の成否は別途問題となり得る。

この点について、既に犯人の身柄が拘束されていた事案において、虚偽供述を行った行為について、判例（最決平29.3.27【百選Ⅱ123】）は、事例判断ながら「被告人の行為は、刑法103条にいう『罪を犯した者』をして現にされている身柄の拘束を免れさせるような性質の行為と認められるのであって、同条にいう『隠避させた』に当たると解するのが相当である」とした。

もっとも、これは、逮捕勾留の後の手続段階における身柄拘束作用のみを問題としたものである。本問のように、虚偽供述を行った段階で、は犯人が特定されていない事案は射程外である。

これを可罰的であると考えた途は大きく分けて2つある。

1つは、身柄確保について、本来的には場所的・空間的な意味ではなく、国家による処罰の追求圏内に確保することとして規範的に捉えられるべきであるとして、身柄確保前についても、虚偽供述は、究極的には身柄拘束作用を危殆化させるものであるとする。

他の1つは、犯人特定作用を保護法益として正面から認め、虚偽供述はその危殆化をもたらすものであるとする。最決平元.5.1【百選Ⅱ122】は、やはり犯人の身柄拘束後において、身代わり犯として申し出

る行為を、主に、身柄拘束作用の危殆化という観点から可罰的であるとしたものであるが、103条を、「捜査、審判及び刑の執行等広義における刑事司法の作用を妨害する者を処罰しようとする趣旨の規定」だとしており、犯人特定作用をも保護法益とする途を残している。下級審判例（札幌高判平17.8.18【百選Ⅱ124】）では、「捜査機関に誰が犯人か分かっていない段階で、捜査機関に対して自ら犯人である旨虚偽の事実を申告した場合には、それが犯人の発見を妨げる行為として捜査という刑事司法作用を妨害し、同条にいう『隠避』に当たることは明らか」であるとしたものがある。

- 2 身代わり犯人として出頭した行為についても、犯人隠避罪の成否が問題となる。

この点については、犯人がすでに身柄拘束されている事案について、最決平元.5.1【百選Ⅱ122】が可罰性を認めているが、本問は身柄拘束前（犯人特定前）の事案である。この点については、上記のような保護法益論の対立とも相まって、理論構成は分かれるだろうが、結論としては可罰的であると解してよいだろう（大判大4.8.24、最決昭35.7.18、最決昭36.3.28参照）。

なお、本罪は抽象的危険犯であり、隠避行為が成功したか否かは問われない（ただし、危険発生の程度等については議論がある。）。

- 3 乙に成立し得る証拠偽造罪、犯人隠避罪について、乙は甲の父親であるから、105条によって刑の任意的な免除がある。
- 4 乙に証拠偽造罪、犯人隠避罪（2つ）を成立させた場合、行為態様や保護法益論についての理解とも関係するが、併合罪とする見解と、包括一罪とする見解が考えられるだろう。

答案構成

第1 乙の罪責

- 1 虚偽供述について、証拠偽造罪（104）の成否
↓
原則否定説
↓
あてはめ
↓
- 2 犯人隠避罪（103）成立
↓
- 3 身代わり行為についても、犯人隠避罪成立
↓
- 4 105条で刑の任意的な免除あり
↓
- 5 上記2つの犯人隠避罪は併合罪（45前段）となる

第2 甲の罪責

- 1 犯人隠避罪の教唆犯の成否
↓
肯定説
↓
- 2 105条準用の可否
↓
否定説
↓
- 3 甲には犯人隠避罪の教唆犯が成立し、刑の任意的な免除は認められない

第1 乙の罪責

1 (1) 乙は甲の逮捕前に、警察官から取調べを受けた際、「窃盗をしたのは、甲ではなく自分である。」との虚偽の内容を告げ、供述調書を作成させた行為について、証拠偽造罪（104条）が成立しないか。

2 (2) この点について、供述調書も「証拠」に当たり得ることから、虚偽の供述をして供述調書を作成させることは、その「偽造」に当たると考えることもできそうである。

3 しかし、刑法は虚偽の供述を処罰する犯罪として偽証罪（169条）を設けているところ、同罪は処罰の対象を、虚偽の陳述をした者のうち、特に法律により宣誓した者に限定している。これは、虚偽の供述を、特に上記のような条件を備えた者に限定して処罰する趣旨であると考えられる。

4 そうすると、少なくとも虚偽の供述をする行為は、169条所定の場合を除き、処罰されないというべきである。そして、この理は、供述調書などの供述を録取した媒体が作成された場合であっても同様である。

5 (3) 本件では、乙の供述内容どおりの警察官面前調書が作成され、供述を録取した媒体が作成されているものの、証拠偽造罪は成立しない。

6 2 一方で、乙には、窃盗（235条）という「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」である甲を「隠避」したものと見て、犯人隠避罪（103条）が成立する。「隠避」とは、蔵匿以外の方法により官憲の逮捕・発見を妨げる一切の行為をいうところ、乙の供述は、究極的には犯人甲の

1

7 身柄の確保を妨げるような内容であり、これに当たるからである。

8 3 さらに、乙が身代わり犯として出頭した点についても、上記と同様の理由により、「隠避」行為に該当するから、犯人隠避罪が成立する。なお、本罪は抽象的危険犯であるから、警察が乙の申し出どおりに乙を逮捕せず、真犯人である甲の逮捕に成功したとしても、本罪の成否には影響がない。

9 4 もっとも、乙は甲の父親であり「親族」であり、上記いずれの行為も甲の「利益のために」行っているから（虚偽供述の点も、甲からの依頼はないものの、甲の「利益のために」行っているものと考えられる。）、105条の適用により、以上の罪に関する乙の刑は任意的に免除される。

10 5 以上より、乙には虚偽の陳述にかかる①犯人隠避罪、身代わり犯としての出頭にかかる②犯人隠避罪が成立し、併合罪（45条前段）となる。ただし、刑の任意的な免除がある。

第2 甲の罪責

11 (1) 甲は、窃盗被疑事件で警察から追われている者であるところ、乙に対して身代わり犯人としての出頭を依頼し、上記行為を行わせた点で、「人を教唆して犯罪を実行させた」（61条1項）として、犯人隠避罪の教唆犯（61条1項）の成立が考えられる。

12 (2) この点について、103条の犯罪の主体には犯人自身は含まれない。同条の文言上「させた」となっているし、犯人には適法行為の期待可能性がないからである。このことから、より犯情において軽い教

2

唆犯は成立しないと解する立場がある。

しかし、共犯の処罰根拠は、正犯を介した間接的な法益侵害に求められるところ、正犯に犯罪が成立する以上、これを教唆すれば法益侵害を引き起こしているといえることができる。

しかも、他人を利用して自己を隠避させることは、自ら蔵匿・隠避するよりもそれが容易になるから、その意味で法益侵害の程度はより高い。

また、このような事態にあつては、定型的に期待可能性がないということではできないし、他人を利用して隠避を図ることは防御権の濫用である。

以上のような諸点に鑑みれば、犯人が他人に隠避を教唆した場合は、教唆犯が成立するとみるべきである。

(3) 本問でも、甲は犯人であるものの、犯人隠避罪の教唆犯が成立することに問題はない。

2 もっとも、乙は、甲の父親であり、上記のように105条が適用されるから、教唆犯たる甲にも同条が準用されないか。

この点について、上記のように他人を教唆して隠避を図ることに期待可能性がないとはいえないところ、その理は、親族を教唆した場合でも妥当するから、同罪の成立が認められることはもちろん、105条の準用も認められないと解すべきである。

3 以上から、甲には犯人隠避罪の教唆犯が成立し、また、それについて刑の任意的な免除は認められない。

3

以 上

4